

1500276-23.2017.8.26.0337

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Camila Mota Giorgetti

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... suficiente para a caracterização do delito de tráfico de drogas.

Irrelevante, assim, que o réu não tenha sido flagrado na prática de atos de venda. De fato, "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque

Foro de Mairinque

1ª Vara

Avenida: Doutor Gaspar Ricardo Júnior, 185, Mairinque-SP - cep 18120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500276-23.2017.8.26.0337 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-23.2017.8.26.0337

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2012151/2017 - DEL.POL.MAIRINQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO JOSE BATISTA DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Mota Giorgetti

Vistos.

THIAGO JOSÉ BATISTA DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado e esta sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, II e III, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 349-A, por sete vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, tudo em concurso material de delitos, porque no dia 12 de novembro de 2017, em horário indeterminado, no período da manhã, nas dependências do estabelecimento prisional de Mairinque, situado na Estrada do Sinindu, 6905, (i) prevalecendo-se da função pública de agente penitenciário, guardava e mantinha em depósito, 1 tijolo contendo aproximadamente 223g de maconha, e uma porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e (ii) promoveu a entrada de sete aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, no estabelecimento prisional acima indicado.

Consta da peça acusatória que o réu trabalhava como agente penitenciário na Penitenciária de Mairinque e, prevalecendo-se dessa função pública, trazia consigo, na data dos fatos, uma mochila com os entorpecentes acima descritos. Na referida mochila estavam, ainda, sete aparelhos de telefonia móvel, sete carregadores de celular, cinco "chips" para aparelhos de telefone celular e cinco fones de ouvido, além de diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefone. O acusado ingressou no estabelecimento com os itens acima mencionados e os guardou no guarda-volumes da Penitenciária. Entretanto, por conta de acidente sofrido durante o trajeto até o presídio, o réu compareceu, no período da manhã, a uma clínica na cidade de Sorocaba. Após tomar conhecimento de que seria necessário submeter-se a um procedimento cirúrgico, o réu pediu a seu pai, por volta das 22:00 horas, que retirasse sua mochila do guarda-volumes. No local, o pai do réu entregou a chave do armário para um agente penitenciário e solicitou a mochila. Contudo, ao ter acesso à mochila, o agente notou que dentro dela havia uma embalagem de um aparelho de telefone celular semelhante a um que havia sido apreendido no interior da unidade na semana anterior. Assim, o agente e seus superiores Rafael e Raimundo constataram odor de maconha no interior da mochila e, revistando-a, encontraram os entorpecentes e os aparelhos celulares.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial e foi recebida a fls. 225/226.

Citado (fls. 426), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 430/431). Durante a instrução foram ouvidas sete testemunhas.

O réu foi declarado revel.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A Defesa do réu, por sua vez, pleiteou a absolvição.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade do delito está comprovada no boletim de ocorrência de fls. 2/6, no auto de apreensão de fls. 16/17 e nos laudos de fls. 62/66, 76/80 e 91/93.

A testemunha Cauê disse que trabalhava com o réu. Disse que ele, Gilmar e o réu estavam indo juntos para o trabalho. Disse que Gilmar perdeu o controle do veículo e que houve um acidente. Disse que foram socorridos por populares e que sua bolsa e a do Gilmar ficaram no carro. Disse que ambos estavam sem suas armas. Disse que não havia objetos de valor na sua mochila ou na de Gilmar. Disse que Thiago preocupou-se em pegar sua mochila para leva-la consigo. Disse que no dia anterior tinham ido a uma festa. Disse que durante a festa deixou sua mochila no carro. Disse que, chegando ao presídio, entraram para conversar com o diretor de portaria e que o réu foi até o guarda-volumes. Disse que não acompanhou o réu nesse momento. Disse que os armários disponibilizados na penitenciária são aleatórios, ou seja, diariamente é registrado em um livro o número do cadeado entregue ao usuário. Disse que havia outro funcionário com nome de Thiago no estabelecimento. Disse que tinha bom relacionamento com o acusado. Disse que não teve conhecimento de que o celular do réu havia sido furtado. Disse que havia quatro funcionários na manutenção, mas em serviço havia sempre dois. Disse que no local dos armários não havia câmeras e que depois dos fatos todas as bolsas passaram a ser escaneadas.

A testemunha Igor disse que conhece o réu por conta das funções que ele exercia no presídio. Disse que ouviu boatos entre os outros presos de que foram encontrados drogas e celulares no armário do acusado. Disse que o réu costumava levar drogas e telefones para o interior dos "raios", que eram negociados com pelo acusado com os presos. Disse que o réu orientava os presos a pedir "manutenção" para que ele fosse até os raios. Disse que o nome dado ao funcionário que leva drogas para o interior dos raios é apelidado de "palhaço". Disse que o réu faria a entrega das drogas e

dos celulares apreendidos na semana seguinte em raio diverso do que se encontrava. Disse que a entrega no seu raio tinha sido feita dias antes. Disse que se recorda que o réu é branco, cabelo preto, forte, magro, encorpado e alto.

A testemunha Luiz Carlos disse que é Diretor da Penitenciária de Mairinque. Disse que o réu estava internado por conta de um acidente e uma terceira pessoa foi buscar seus pertences. Disse que a mochila foi aberta para certificar se ela realmente pertencia ao réu. Disse que os armários ficam na portaria e os usuários são registrados em livro. Disse que cada armário tem um cadeado e que as chaves são exclusivas, ou seja, não se prestam a abrir mais de um cadeado. Disse que não acompanhou a revista da mochila e que foi informado dos fatos pelo diretor de segurança. Disse que havia informações de que havia um funcionário intermediando a entrega de objetos ilícitos aos presos, os quais, depois dos fatos, confirmaram que era o réu. Disse que o réu responde a processo administrativo na corregedoria.

A testemunha Fábio disse que atualmente é diretor de finanças do presídio. Disse que no dia dos fatos saiu do plantão e soube que o réu tinha se acidentado e que havia deixado suas coisas no armário da unidade. Disse que o réu ligou do hospital pedindo para que acompanhasse seu pai até o presídio para que ele pegar a mochila que estava no armário. Disse que o pai do réu passou em sua casa e foram juntos até a penitenciária. Disse que o pai do réu não quis entrar e que foi até portaria sozinho. Disse que o pai do réu trouxe a chave do armário, que tinha sido entregue pela manhã ao acusado. Disse que, no dia, quem estava de plantão na portaria era Juliano, que também é de Assis. Disse que pegou a mochila e que ficou um tempo conversando com Juliano e que acabou se demorando, por isso foi apressado pelo pai do réu. Disse que Juliano, para confirmar se a mochila realmente pertencia ao réu, abriu-a. Disse que encontraram uma caixa de celular, semelhante a um que havia sido apreendido junto aos presos. Disse que acionaram Rafael e Raimundo e que encontraram outros celulares e drogas. Disse que não há armários fixos e que chave, cadeado e armário têm o mesmo número. Há cópias das chaves para casos de extravio. Disse que quando a mochila foi aberta, os superiores e o pai do acusado foram chamados. Disse que há outro Thiago no estabelecimento, mas ele trabalha em outro setor e é tratado por Richard. Disse que o réu não tinha desafetos no estabelecimento. Disse que, no entanto, havia comentários vindos do outro estabelecimento onde o réu trabalhou no sentido de que era necessário ter cuidado com ele.

A testemunha Raimundo disse que trabalha no presídio como diretor de plantão. Disse que no dia dos fatos estava de plantão e foi chamado porque o pai tinha ido buscar pertences do réu e que tinham sido localizados celulares e maconha. Disse que a revista da mochila do réu foi acompanhada pelo pai do réu e pelos funcionários Juliano e Fábio. Disse que foi chamado assim que a mochila foi aberta. Disse que havia controle para entrega das chaves dos armários. Disse que não há armários exclusivos e que o armário foi aberto com a chave que o pai do réu trazia consigo. Disse que os armários em questão eram utilizados apenas por funcionários. Disse que, na época, o réu trabalhava sozinho.

A testemunha Rafael disse que na época dos fatos trabalhava como diretor de segurança e disciplina. Disse que foi chamado até a portaria para verificar a bolsa do acusado. Disse que no dia, pela manhã, Thiago sofreu acidente e deixou a bolsa no estabelecimento antes de ir para o hospital. Disse que foram visita-lo no final da tarde e que o acusado disse que o pai iria auxiliá-lo e que, provavelmente, iria buscar a bolsa no estabelecimento. Disse que na noite daquele dia o pai do réu chegou junto com Fábio para pegar a bolsa. Disse que o armário do réu foi aberto com a chave que tinha sido entregue a ele no período da manhã. Disse que a designação do armário e da chave é feita mediante registro. Disse que a revista na bolsa foi feita porque havia ocorrido a mudança do plantão e o funcionário que lá estava queria se certificar de que a bolsa era, realmente, do réu. Disse que não havia suspeitas em relação ao réu, que trabalhava no estabelecimento desde sua

inauguração. Disse que, posteriormente, houve apuração e que confirmaram que o réu negociava com presos a entrega de celulares. Disse que a notícia ocorreu por conta do depoimento de um preso, que não sabe se foi prestado antes ou depois dos fatos. Disse que foram localizados sete celulares, cinco carregadores, um tijolo de maconha, anotações e alguns itens pessoais, como o crachá. Disse que o pai do réu acompanhou a revista da mochila. Disse que um mês antes dos fatos foi feita uma revista no estabelecimento e foi apreendido um aparelho celular, marca LG. Disse que o funcionário que pegou a mochila do acusado viu a caixa de um celular idêntico a esse. Disse que isso chamou a atenção do funcionário porque não é um celular moderno e, portanto, não é o utilizado por pessoas com o poder aquisitivo do réu. Disse que, pelo que se recorda, não havia outro funcionário de nome Thiago fazendo uso de armário no dia dos fatos. Disse que a cópia das chaves fica no setor administrativo, que permanece fechado nos finais de semana. Disse que o furto da arma que ocorreu antes dos fatos não se deu no mesmo local onde estava a mochila do réu.

Inicialmente, deve ser ressaltado que não há irregularidade ou nulidade a ser reconhecida no presente caso. De fato, apurou-se que o acusado estava em poder de sua mochila e a deixou no armário destinado aos servidores do estabelecimento penitenciário. De acordo com os responsáveis pelo setor, cada servidor que fizesse uso dos armários recebia um cadeado com a respectiva chave.

Conforme relatado pelas testemunhas, o armário somente foi aberto a partir da chave que se encontrava em poder do acusado e que fora entregue ao seu pai, o qual havia sido encarregado de buscar a mochila na data dos fatos. A chave, aliás, foi entregue aos agentes responsáveis pelo setor em que se localizava os armários pelo pai do próprio acusado.

Não se olvide, ainda, que os delitos imputados ao acusado têm natureza permanente, de forma que a consumação e, em consequência, o estado de flagrância, protraem-se no tempo.

No mais, as declarações das testemunhas estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase policial. Verifica-se, ainda, que a narrativa dos agentes penitenciários contém detalhes sobre como se deram os fatos, o que confere verossimilhança a seus relatos. Ademais, seus depoimentos foram coerentes e se harmonizam com a narrativa feita à autoridade policial, razão pela qual merecem credibilidade.

Cumpra mencionar que é inquestionável a validade do depoimento prestado pelos Agentes Penitenciários. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.

Não restam dúvidas, ainda, de que a droga, pela forma como se encontrava acondicionada, seria entregue para uso dos detentos da Penitenciária de Mairinque, circunstância que se mostra suficiente para a caracterização do delito de tráfico de drogas.

Irrelevante, assim, que o réu não tenha sido flagrado na prática de atos de venda. De fato, "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

Há que se observar, ainda, que a simples condição de usuário, ainda que

efetivamente demonstrada, não afasta a responsabilidade pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, principalmente quando o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o entorpecente apreendido destinava-se à entrega a terceiros.

O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. É o que ocorreu nos autos, vez que os elementos de convicção trazidos aos autos permitem a segura conclusão de que o tijolo de maconha, seria introduzido nos pavilhões onde se encontram os sentenciados da Penitenciária de Mairinque e entre eles distribuído.

Deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Com efeito, os fatos ocorreram dentro do estabelecimento prisional, portanto, fica autorizada a incidência da majorante. Nesse sentido, saliento que, para a incidência da majorante em questão, pouco importa se o agente é preso ou pessoa estranha ao presídio. O tipo penal não faz tal diferença, pois é particularmente grave, já que praticado em local onde, em tese, se almeja a ressocialização e reeducação dos condenados.

Incide no presente caso, ainda, a majorante do art. 40, II, da Lei nº 11.343/06, pois não restam dúvidas de que o acusado era servidor público e de que se valeu dessa condição para praticar o delito de tráfico. De fato, o réu aproveitou-se da sua condição de agente penitenciário para promover a distribuição de entorpecentes no presídio. Note-se que, de acordo com o relato das testemunhas, o acusado valia-se, inclusive, da sua designação para atuar no setor de manutenção do estabelecimento, vez que havia acertado com os detentos que, para que lhes fosse fornecida a droga, deveriam solicitar manutenção da cela ou do raio em que se encontravam.

O crime do art. 349-A do Código Penal, por sua vez, incrimina a conduta daquele que promove, ou seja, dá causa, dá impulso, diligência no sentido de viabilizar a entrada de aparelho telefônico no interior estabelecimento prisional.

Trata-se de crime de perigo abstrato, pelo que desnecessário o efetivo acesso do detento ao aparelho de telecomunicação.

No caso dos autos, restou demonstrado que o acusado tinha em seu poder aparelhos de telefonia celular semelhantes a outros que já tinham sido apreendidos em data pregressa, e cujos modelos são comumente utilizados pelos sentenciados, de forma clandestina. Não há dúvida, portanto, de que o acusado promoveu a entrada de aparelhos telefônicos no estabelecimento prisional, com vistas a promover a driblar a proibição de acesso dos sentenciados a tais aparelhos de comunicação.

Todavia, conquanto tenham sido localizados diversos aparelhos na mochila do acusado, deve ser reconhecida a prática de um único crime. A quantidade de aparelhos constitui, na verdade, circunstância judicial, a ser avaliada no momento da fixação da pena.

Desta forma, demonstradas a autoria e a materialidade, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico que culpabilidade, entendida esta como reprovação da conduta, no caso concreto, é de mediana intensidade. No tocante à sua conduta social, as informações dos autos permitem enquadrá-lo na moral social média. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500

(quinhentos) dias multa, para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao delito do art. 349-A, do Código Penal, observo que o acusado promoveu a entrada de, pelos menos, sete aparelhos de telefonia celular no estabelecimento prisional em que exercia suas funções. Tal circunstância, sobretudo considerando-se a possibilidade de compartilhamento do telefone entre vários sentenciados, aponta para a maior gravidade da conduta e, portanto, autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

Desta forma, fixo a pena base para o delito do art. 349-A, do Código Penal, em 4 meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Presentes as causas de aumento do art. 40, II e III, da Lei nº 11.343/06, nos termos da fundamentação acima, elevo a pena em 1/4, atingindo 6 anos e 3 meses de reclusão, mais pagamento de 625 dias multa.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu é primário, inexistindo notícias de que integre organização criminosa ou de que tenha feito da prática de crimes uma rotina em sua vida. Assim, possível a redução prevista no mencionado dispositivo. Considerado, porém, as circunstâncias dos autos, em especial o fato de se tratar de servidor público cuja conduta contraria por completo as funções que lhe foram confiadas pelo Estado, reduzo a pena em 1/6, atingindo 5 anos e 2 meses de reclusão, mais pagamento de 520 dias-multa.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena de reclusão será o semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, do Código Penal, diante da inconstitucionalidade do art. 2, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Tratou-se, evidentemente, de controle difuso de constitucionalidade, despojado de formal eficácia vincula erga omnes, até que, eventualmente, exista o procedimento previsto no art. 52, X, da Constituição. Por outro lado, ainda que assim não fosse, o STF também entendeu que o chamado tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos (STF, HC 118.533, j. 23.06.2016).

Ressalvando meu entendimento pessoal sobre a matéria, revejo-o para me curvar a essas orientações, tomadas pelo Pleno da Suprema Corte, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, importantíssimos à coesão de nosso Estado de Direito, já que o papel do STF deve ser modernamente compreendido como Corte Suprema de promoção da unidade do Direito (em especial, questões de Direito Constitucional), mediante a formação de precedentes.

A pena de detenção, por sua vez, será cumprida inicialmente no regime aberto.

Inviável, por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois superado o limite previsto no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMETNE PROCEDENTE a presente ação penal para declarar THIAGO JOSÉ BATISTA DE CASTRO como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, II e III, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 349-A, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento de 520 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Tratando-se de funcionário público, determino, ainda, a perda da função pública, nos termos do art. 92 do Código Penal.

O réu não se encontra preso por conta deste processo. Além disso, considerando o regime fixado para início do cumprimento da pena, entendo que não se fazem presentes os requisitos da prisão cautelar, pelo que poderá o réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade.

PIC

Mairinque, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA